

Die Anhörungsrüge in der neuesten Rechtsprechung des BVerfG

(Problematische) Tendenzen und Hinweise zur Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden*

Rechtsanwalt Dr. Jan Felix Sturm, Hamburg

Die Anhörungsrüge – vom Bundesverfassungsgericht 2003 gefordert, seit 2005 Gesetz – sollte nicht nur den Rechtsschutz verbessern, sondern auch das Bundesverfassungsgericht entlasten. Ob diese Wirkung erreicht worden ist, mag dahingestellt bleiben. Sicher ist nur, dass Anwältinnen und Anwälte nun mit Blick auf Rechtswegerschöpfung, Subsidiarität und Frist der Verfassungsbeschwerde vor schwierigen taktischen Fragen stehen. Die Varianten fächert der Autor auf und zeigt, wie der sicherste Weg aussieht. Zugleich appelliert er an das Bundesverfassungsgericht, seine (Kammer-)Rechtsprechung anwalts- und damit mandantenfreundlicher auszugestalten.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist ein objektivrechtliches Verfahrensprinzip, das für ein rechtsstaatliches Verfahren schlechthin konstitutiv ist. Zugleich ist es „prozessuales Unrecht“ des Menschen, indem es seine Subjektstellung im Verfahren sichert.¹ Art. 103 Abs. 1 GG gehört in der Fallpraxis des BVerfG zu denjenigen Rechten, die am häufigsten mit der Verfassungsbeschwerde als verletzt gerügt werden.² Der Weg zu seiner erfolgreichen Geltendmachung mittels Verfassungsbeschwerde ist allerdings mit zahlreichen Fallstricken verbunden, die aus dem Zusammenspiel des fachgerichtlichen Rechtsbehelfs der Anhörungsrüge mit dem Verfassungsprozessrecht resultieren. Der folgende Beitrag versucht einen systematischen Überblick zum aktuellen Stand der Rechtsprechung des BVerfG zur Anhörungsrüge zu geben, problematische Entwicklungen in der Entscheidungspraxis des Gerichts zu identifizieren und sowohl praxistaugliche Handlungsempfehlungen für den Rechtsanwalt als auch Vorschläge für die künftige Entwicklung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu formulieren.

Im Folgenden gilt es zuerst, den Inhalt des Rechts auf rechtliches Gehör (I.) und die Anhörungsrüge als fachgerichtlichen Rechtsbehelf (II.) zu skizzieren. In der Hauptsache werden dann die verfassungsprozessualen Probleme, die mit der Anhörungsrüge einhergehen, anhand der neuesten Rechtsprechung beschrieben (III.), bevor mit dem „Parken im Allgemeinen Register“ ein rechtssicherer, wenngleich aufwändiger Weg zur Vermeidung bestehender Risiken geschildert wird (IV.). Abschließend fasst der Beitrag die praktischen Hinweise an den Rechtsanwalt zusammen. Verbunden sind diese Hinweise an die Rechtsanwaltschaft mit punktuellen Anregungen, wie das BVerfG seinen Rechtsschutzauftrag vorhersehbarer und effektiver erfüllen könnte (V.).

I. Das Recht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG)

„Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.“ Die lakonisch formulierte Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG gewährleistet ein grundrechtsgleiches Recht (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG), das einen dreifachen Gewährleistungsgehalt aufweist (1.). Es steht in enger Beziehung zum einfachen Prozessrecht (2.) und weist zahlreiche Überschneidungen mit verwandten grundrechtlichen Gewährleistungen auf (3.).

1. Gewährleistungsgehalte

Zunächst enthält Art. 103 Abs. 1 GG ein Recht auf *Information* über das prozessuale Geschehen und den tatsächlichen Verfahrensstoff,³ weil dies die Voraussetzung für eine informierte Äußerung der Prozesspartei ist. Die Verfassungsbestimmung verpflichtet die Gerichte zwar grundsätzlich nicht zu einem Rechtsgespräch, schützt aber vor Überraschungsentscheidungen. Ein Gericht darf nämlich ohne vorherigen Hinweis nicht auf einen rechtlichen Gesichtspunkt abstellen, mit dem ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter nach dem bisherigen Prozessverlauf – selbst unter Berücksichtigung der Vielfalt vertretbarer Rechtsauffassungen – nicht zu rechnen brauchte.⁴

Sodann gewährleistet Art. 103 Abs. 1 GG ein Recht auf *Äußerung*, also die Möglichkeit, sich zum gesamten Verfahrensstoff und zur Rechtslage zu äußern sowie Anträge zu stellen.⁵ Ist ein Verfahrensbeteiligter anwaltlich vertreten, so garantiert Art. 103 Abs. 1 GG die anwaltlichen Äußerungsmöglichkeiten.⁶

Drittens schließlich enthält Art. 103 Abs. 1 GG eine Pflicht zur *Berücksichtigung* des Vorbringens: Die Gerichte haben das Parteivorbringen zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen.⁷ Damit ist zunächst ein innerer Vorgang des erkennenden Gerichts geboten. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass er stattgefunden hat, auch wenn das Gericht in seiner Entscheidung zu dem jeweiligen Parteivortrag schweigt. Denn Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet nicht dazu, in der Begründung einer Entscheidung jedes Vorbringen umfassend zu bescheiden;⁸ diese Begrenzung soll namentlich bei letztinstanzlichen Entscheidungen gelten.⁹ Wird Parteivortrag in einer gerichtlichen Entscheidung nicht aufgegriffen, so kann das BVerfG nach alledem einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG nur dann annehmen, wenn besondere Umstände im Einzelfall deutlich ergeben, dass das Vorbringen nicht erwogen wurde. Solche Umstände sind das fehlende Eingehen auf den Kern des Tatsachenvortrags zu einer Frage, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, sofern der Vortrag nicht vom Rechtsstandpunkt des Gerichts aus unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert ist.¹⁰ Dieser Maßstab kann

* Dank für hilfreiche Anmerkungen gebührt Johannes Gerberding und Dr. Daniel Schneider.

1 BVerfGE 55, 1 (6); 107, 395 (408).

2 Lenz/Hansel, BVerfGG, 2. Aufl. 2015, § 90 Rn. 227. Statistisches Material zur Häufigkeit bestimmter Grundrechtsrügen ist nicht veröffentlicht.

3 BVerfGE 89, 28 (35).

4 BVerfGE 108, 341 (345f.).

5 BVerfGE 64, 135 (143f.).

6 BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 16.7.2016 – 2 BvR 1614/14, juris, Rn. 14.

7 BVerfGE 11, 218 (220); 96, 205 (216).

8 BVerfGE 22, 267 (274); 96, 205 (216f.).

9 BVerfGE 65, 293 (295); vgl. auch Höger, juris PR-BGHZivilR 19/2017 Anm. 3.

10 BVerfGE 86, 133 (146); BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 29.10.2015 – 2 BvR 1493/11, juris, Rn. 45.

ebenfalls auf den Kern des rechtlichen Vortrages angewandt werden.¹¹

2. Zusammenspiel mit dem einfachen Prozessrecht

Art. 103 Abs. 1 GG wirkt zum einen als Vorgabe an den Gesetzgeber, die dieser bei der Ausgestaltung der Prozessordnungen beachten muss. Das grundrechtsgleiche Recht steht dann gleichsam hinter den Normen des einfachen Prozessrechts. Dieses kann aber auch Vorkehrungen treffen, die über das verfassungsnotwendige Minimum an rechtllichem Gehör hinausgehen.¹² So ist etwa die richterliche Hinweispflicht nicht in dem durch § 139 ZPO normierten Ausmaß verfassungsgeboten; eine stärkere Akzentuierung der Selbstverantwortung der Parteien durch den Gesetzgeber wäre verfassungsrechtlich zulässig.¹³ Zum anderen wendet sich die Verfassungsbestimmung unmittelbar an die Gerichte und greift auch ein, wenn in den Verfahrensordnungen besondere Regelungen fehlen.¹⁴

Verstößt ein Gericht gegen gehörsbezogene Regelungen des einfachen Prozessrechts, liegt darin eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG, wenn Bedeutung und Tragweite des Grundrechts verkannt werden.¹⁵ Davon wird man bei der willkürlich fehlerhaften oder offensichtlich unrichtigen Anwendung von Vorschriften, die das rechtliche Gehör ausgestalten, ausgehen können.¹⁶

3. Zusammenspiel mit verwandten Grundrechtsgewährleistungen

Art. 103 Abs. 1 GG steht in Nachbarschaft zu und überschneidet sich mit anderen (prozess-)grundrechtlichen Verfassungsgewährleistungen.

a) Rechtsschutzgarantie

Zunächst besteht ein funktionaler Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie, die gegenüber Akten der öffentlichen Gewalt aus Art. 19 Abs. 4 GG und im Übrigen, das heißt insbesondere im Verhältnis zweier Privater zueinander, aus dem allgemeinen Justizgewährleistungsanspruch folgt. Der Zugang zum Gericht (sowie zu einer weiteren Instanz, sofern die jeweilige Prozessordnung eine solche vorsieht) darf dabei nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden.¹⁷ Die Rechtsschutzgarantie sichert dabei den Zugang zum Verfahren, während Art. 103 Abs. 1 GG den angemessenen Ablauf des Verfahrens gewährleistet.¹⁸

Mit anderen Worten: Wer bei Gericht formell ankommt (was die Rechtsschutzgarantie sichert), soll infolge des rechtlichen Gehörs auch substantiell ankommen.¹⁹ Eine Überschneidung zwischen beiden Gewährleistungen wird vom BVerfG insbesondere bei Wiedereinsetzungsanträgen angenommen: Da die Wiedereinsetzungsgewährung Voraussetzung dafür ist, dass sich die Partei Gehör verschaffen kann, folgt sowohl aus Art. 103 Abs. 1 GG als auch aus der Rechtsschutzgarantie ein Verbot, die Anforderungen an die Wiedereinsetzung zu überspannen.²⁰ Zwingend ist dieser Gleichlauf der Gewährleistungen nicht. Auch hier bauen der formelle (wiederzueröffnende) Zugang zu Gericht (ggf. zur nächsten Instanz bei versäumten Rechtsmittel- oder Rechtsmittelbegründungsfristen) und die Möglichkeit, mit dem in der Sache anzubringenden Vortrag durchzudringen, aufeinander auf.

b) Faires Verfahren

Als die Subjektstellung im Verfahren währendes „Urrecht“ weist Art. 103 Abs. 1 GG eine enge Beziehung zum Grundsatz des fairen Verfahrens auf, der auf verfassungsrechtlicher Ebene durch Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gewährleistet ist. So betrachtet das BVerfG Überraschungsentscheidungen zugleich als Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG und als Verstoß gegen das Gebot des fairen Verfahrens.²¹

c) Willkürverbot

Zuletzt schließlich treten Überschneidungen mit dem allgemeinen Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG, auf. Dieser wirkt gegenüber der Rechtsprechung als Verbot willkürlicher Entscheidungen. Willkürlich sind dabei Entscheidungen, die unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar sind und bei denen sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruhen. Davon ist etwa auszugehen, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt wird.²² Wird eine den Anspruch auf rechtliches Gehör sichernde Vorschrift des einfachen Prozessrechts in willkürlicher Weise gehandhabt, liegt somit gleichermaßen ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG wie gegen Art. 103 Abs. 1 GG vor. Stützt ein Gericht seine Entscheidung auf eine willkürlich gehandhabte Vorschrift (auch des materiellen Rechts), ohne die Parteien vorher auf seinen Rechtsstandpunkt hingewiesen zu haben, liegt darin zugleich eine Überraschungsentscheidung.²³

Aus anwaltlicher Perspektive folgt daraus, dass in verschiedensten Konstellationen prozessualen Unrechts auch ein Verstoß gegen das Gebot rechtlichen Gehörs in Betracht zu ziehen ist.

II. Die Anhörungsrüge als fachgerichtlicher Rechtsbehelf

Mit Plenarbeschluss vom 30. April 2003 hat das BVerfG ausgesprochen, dass der allgemeine Justizgewähranspruch die gesetzliche Bereitstellung einer einmaligen fachgerichtlichen Überprüfungsmöglichkeit fordere, mit der behauptete Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör seitens eines Gerichts gerügt werden können.²⁴ Dem ist der Gesetzgeber mit dem Anhörungsrügensgesetz mit Wirkung zum 1. Januar

11 BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats v. 14.9.2016 – 1 BvR 1304/13, juris, Rn. 21 ff.

12 Vgl. Eichberger, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 138 (Stand: September 2003) Rn. 73.

13 Kern, in: Stein/Jonas, ZPO, Bd. 2, 23. Aufl. 2016, vor § 128 Rn. 86.

14 BVerfGE 9, 89 (96); 89, 381 (390).

15 BVerfGE 119, 292 (296).

16 Vgl. BVerfGE 69, 145 (149); BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 16.7.2016 – 2 BvR 1614/14, juris, Rn. 21.

17 BVerfGE 42, 128 (130); 78, 88 (98 f.); 104, 220 (232).

18 BVerfGE 107, 395 (409).

19 BVerfGE 119, 292 (296).

20 BVerfGE 42, 128 (130 ff.); BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 18.10.2012 – 2 BvR 2776/10, juris, Rn. 14 ff.

21 BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats v. 14.10.2010 – 2 BvR 409/09, juris, Rn. 20; Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 25.4.2015 – 1 BvR 2314/12, juris, Rn. 20;

22 BVerfGE 87, 273 (278 f.); 96, 189 (203).

23 Vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats v. 4.7.2016 – 2 BvR 1552/14, juris, Rn. 6 ff.

24 BVerfGE 107, 395.

2005 nachgekommen,²⁵ mit dem die Anhörungsrüge in den einzelnen Prozessordnungen eingeführt beziehungsweise modifiziert wurde (§ 321a ZPO, § 78a ArbGG, § 44 FamFG, § 152a VwGO, § 178a SGG, § 133a FGO, § 33a StPO, gegebenenfalls in Verbindung mit § 120 Abs. 1 Satz 2 StVollzG, § 356a StPO). Das Gesetz verfolgt zwei Ziele: Rechtsschutz gegen Gehörsverletzungen auf der einen Seite, Entlastung des BVerfG auf der anderen.²⁶ Als typisches Beispiel der einander ähnlichen Einzelregelungen soll hier § 321a ZPO kurz skizziert werden.

1. Die Zulässigkeit einer Anhörungsrüge

Die zum *iudex a quo* zu erhebende Anhörungsrüge ist zulässig gegenüber Endentscheidungen, gegen die kein sonstiger Rechtsbehelf mehr gegeben ist. Zu diesen Entscheidungen zählen Revisionsentscheidungen, Berufungsentscheidungen ohne Revisionszulassung mit einer geltend zu machenden Beschwer bis zu 20.000 Euro (§ 26 Nr. 8 EGZPO)²⁷ und Entscheidungen ohne Berufungszulassung mit einem Wert des Beschwerdegegenstandes bis 600 Euro (§ 511 Abs. 2 ZPO). Auch gegen letztinstanzlichen Entscheidungen im Eilverfahren ist die Anhörungsrüge statthaft.²⁸ Ebenso ist sie – in verfassungskonformer teleologischer Reduktion von § 321a Abs. 1 Satz 2 ZPO – zulässig gegenüber Zwischenentscheidungen, die im weiteren Verfahren keiner Kontrolle bezüglich Gehörsverstößen mehr unterliegen.²⁹ Eine zweite Anhörungsrüge, also eine Anhörungsrüge gegen Entscheidungen nach § 321a ZPO, ist nicht statthaft.³⁰ Die Rüge ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Kenntnis vom Gehörsverstoß zu erheben (§ 321a Abs. 2 Satz 1 ZPO).³¹

Für eine zulässige Rüge sind die Verletzung rechtlichen Gehörs und der Beruhenszusammenhang zwischen Gehörsverletzung und Entscheidung (im Sinne einer potentiellen Kausalität) darzulegen (§ 321a Abs. 2 Satz 5 ZPO). Zudem ist nach § 321a Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 ZPO der Zeitpunkt der Kenntniserlangung glaubhaft zu machen. Mit der Anhörungsrüge können allein Verstöße gegen Art. 103 Abs. 1 GG,³² nicht aber gegen sonstige Prozessgrundrechte geltend gemacht werden.³³ Nicht gerügt werden kann im Übrigen der bloße Umstand, dass einem vorinstanzlichen Gehörsverstoß, den die Partei im Rahmen eines Rechtsmittels angegriffen hatte, nicht abgeholfen worden ist (sog. sekundäre Anhörungsrüge); es bedarf vielmehr eines neuen und eigenständigen Gehörsverstoßes durch die letzte Instanz.³⁴

2. Begründetheit einer Anhörungsrüge

Begründet ist die Rüge, wenn rechtliches Gehör verletzt worden ist und die Entscheidung darauf beruht. Bei Begründetheit der Anhörungsrüge wird das Verfahren fortgeführt, soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist (§ 321a Abs. 5 ZPO). Zu beachten ist dabei: Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG kann sogar im Rahmen einer zurückweisenden Entscheidung über die Anhörungsrüge geheilt werden, sofern dies durch bloße Rechtsausführungen möglich ist.³⁵ Dies ist dann der Fall, wenn das Gericht Rechtsausführungen nicht zur Kenntnis genommen hat, die für das Gericht nicht durchgreifen, beziehungsweise wenn es auf nicht gehörten Tatsachenvortrag vom Rechtsstandpunkt des Gerichts nicht ankommt.

III. Verfassungsprozessuale Folgen der Anhörungsrüge

Für die nun darzulegenden verfassungsprozessualen Konsequenzen des Anhörungsrügeverfahrens ist zwischen Verfassungsbeschwerden zu unterscheiden, die *ohne* vorherige Anhörungsrüge erhoben werden (1.), und solchen, die *nach* Durchführung eines Anhörungsrügeverfahrens eingelegt werden (2.).

1. Verfassungsbeschwerden ohne vorherige Anhörungsrüge

Innerhalb der ohne vorherige Anhörungsrüge erhobenen Verfassungsbeschwerden ist nochmals zu differenzieren zwischen Situationen, in denen mit der Verfassungsbeschwerde ausdrücklich oder der Sache nach eine Verletzung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) gerügt wird (unter a)), und solchen Fällen, in denen der Beschwerdeführer ausschließlich andere Grundrechtsverletzungen geltend macht (unter b)).

a) Verfassungsbeschwerden mit Art.-103-Abs.-1-Rüge: fehlende Rechtswegerschöpfung

Für die Rüge einer Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG gehört die Anhörungsrüge nach § 321a ZPO etc. zum Rechtsweg.³⁶ Ist das Anhörungsrügeverfahren nicht durchlaufen worden, ist eine Verfassungsbeschwerde, die Art. 103 Abs. 1 GG ausdrücklich oder der Sache nach als verletzt rügt, mangels Rechtswegerschöpfung (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) unzulässig.³⁷ Die Ausnahmen vom Gebot der Rechtswegerschöpfung nach § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG haben insoweit kaum praktische Bedeutung erlangt. Auch in Eilsituationen wird ein strenger Maßstab angelegt.³⁸

Werden neben einer Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG noch weitere Grundrechtsverletzungen geltend gemacht, so ist die ohne Anhörungsrüge erhobene Verfassungsbeschwer-

²⁵ BGBl. I, S. 3220.

²⁶ Leibold, in: Stein/Jonas, ZPO, Bd. 4, 22. Aufl. 2008, § 321a Rn. 3.

²⁷ Ansonsten ist die Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO gegeben, mit der (als Fall des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO) auch Verstöße gegen Art. 103 Abs. 1 GG gerügt werden können, siehe BGHZ 154, 288 (254f.); vgl. auch § 544 Abs. 7 ZPO.

²⁸ Vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 27.9.2017 – 1 BvR 1979/17, juris, Rn. 2.

²⁹ BVerfGE 119, 292 (298ff.).

³⁰ BayVerfGH, NJW-RR 2011, 430; BGH, Beschluss v. 10.2.2012 – V ZR 8/10, juris, Rn. 2; im Strafverfahren ist umstritten, inwiefern gegenüber einer Entscheidung nach § 33a StPO die Beschwerde nach § 304 StPO eröffnet ist, vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 13.10.2015 – 2 BvR 2436/14, juris, Rn. 18.

³¹ Besonderheiten bestehen insofern bei § 356a StPO (Frist von einer Woche) und § 33a StPO (keine Fristbindung); vgl. zu Letzterem noch unten in Fn. 73.

³² So etwa BGH, NJW 2008, 2126 (2127); Leibold, in: Stein/Jonas, a. a. O., Rn. 38; a. A. (einfachrechtlicher Verstoß gegen gehörsverfügende Vorschriften ausreichend) Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 321a Rn. 3a. Mit Blick auf das Verwaltungs- und das Finanzprozessrecht spricht für Letzteres etwa, dass die ohne Beschränkung auf Verfassungsverstöße vom rechtlichen Gehör sprechenden Vorschriften zur Anhörungsrüge insoweit ebenso formuliert sind wie die auf Gehörsverstöße abstellenden Rechtsbehelfsvorschriften (§ 138 Nr. 3 VwGO, § 119 Nr. 3 FGO), bei denen auch der „nur“ einfachrechtliche Gehörsverstoß den Instanzzugang eröffnet, vgl. Rudisile, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 152a (Stand: Oktober 2015) Rn. 18a.

³³ BGH, NJW 2011, 1516; BFHE 209, 419 (421).

³⁴ BGH, NJW 2008, 2126 (2127); BVerfG, NJW 2009, 457.

³⁵ BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 15.7.2016 – 2 BvR 857/14, juris, Rn. 11; zur Abgrenzung vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 14.12.2015 – 2 BvR 3073/14, juris, Rn. 12; näher zur Heilung Gertler, Neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Anhörungsrüge, in: Emmenegger/Wiedmann (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 2, 2011, S. 53 (68ff.).

³⁶ BVerfGE 122, 190 (198).

³⁷ BVerfGE 134, 106 (113); BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 7.10.2016 – 2 BvR 1313/16, juris, Rn. 2 ff.

³⁸ Vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats v. 26.6.2017 – 2 BvR 1353/17, juris, Rn. 1; Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 27.6.2017 – 1 BvR 1390/17, juris, Rn. 1.

de grundsätzlich im Ganzen unzulässig.³⁹ Dies soll gelten, sofern die Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG und die weiteren gerügten Grundrechtsverstöße denselben Streitgegenstand betreffen;⁴⁰ diese Einschränkung ist freilich in der bisherigen Rechtsprechung, soweit ersichtlich, noch nicht wirksam geworden. Die geschilderte Rechtsprechungslinie rechtfertigt sich durch den Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde und die Prozessökonomie: Bei Erfolg der Anhörungsrüge wäre das fachgerichtliche Verfahren wiedereröffnet worden, so dass auch eine Möglichkeit zur Beseitigung anderer Grundrechtsverletzungen bestanden hätte.⁴¹

Eine Ausnahme von der Unzulässigkeitsfolge greift dann, wenn die Anhörungsrüge offensichtlich aussichtslos gewesen wäre.⁴² In diesem Falle kann zwar an der Rüge des Art. 103 Abs. 1 GG (naturgemäß) „nichts dran sein“, allerdings sind immerhin die anderen Grundrechtsrügen zulässig und der Weg zu einer Sachentscheidung des BVerfG eröffnet.

Für den Rechtsanwalt folgt daraus, dass von einem „Andicken“ einer ohne vorherige Anhörungsrüge erhobenen Verfassungsbeschwerde mit einer leichthin gerügten Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG gewarnt werden muss.⁴³ Fällt dies erst auf, nachdem die Verfassungsbeschwerde bereits erhoben ist (gegebenenfalls aufgrund einer Zuschrift des Allgemeinen Registers des BVerfG⁴⁴), sollte die Rüge des Art. 103 Abs. 1 GG in der Verfassungsbeschwerde fallengelassen werden.⁴⁵ Dies ist noch im Verfassungsbeschwerdeverfahren bis zur Entscheidung möglich,⁴⁶ kann allerdings (aufgrund des sogleich Auszuführenden) das Unzulässigkeitsrisiko keineswegs sicher begrenzen.⁴⁷

b) Verfassungsbeschwerden ohne Art.-103-Abs.-1-Rüge: Subsidiaritätsrisiko

Ist keine Anhörungsrüge erhoben worden und wird auch mit der Verfassungsbeschwerde keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG geltend gemacht, erscheint dies auf den ersten Blick schlüssig: Nach Auffassung der beschwerten Partei liegt keine Gehörsverletzung vor, so dass keine Veranlassung zur Erhebung einer Anhörungsrüge bestand. Gleichwohl kann sich der verfassungsprozessuale Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde hier nachteilig auswirken: Nach diesem Grundsatz muss ein (späterer) Verfassungsbeschwerdeführer alle nach Lage der Dinge zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten ergreifen, um die geltend gemachte Grundrechtsverletzung schon im fachgerichtlichen Verfahren zu verhindern oder zu beseitigen.⁴⁸ Diese Obliegenheit bezieht sich wegen des Gebotes der Rechtsmittelklarheit nur auf geschriebene Rechtsbehelfe (worunter die Anhörungsrüge selbstverständlich fällt),⁴⁹ kann allerdings im Rahmen der geschriebenen Rechtsbehelfe durchaus als „Obliegenheit zum Experimentieren“ wirken.⁵⁰ Begrenzt wird der Subsidiaritätsgrundsatz durch Zumutbarkeitsgesichtspunkte: Offensichtlich unzulässige (zuweilen wird auch formuliert: offensichtlich aussichtslose⁵¹) Rechtsbehelfe müssen nicht ergriffen werden.⁵²

Die nach der letzten fachgerichtlichen Sachentscheidung von der unterliegenden Partei zu treffende Beurteilung, ob die Erhebung einer Anhörungsrüge (zur Vorbereitung einer Verfassungsbeschwerde) zu versuchen sei, kann insofern besonders schwierig sein, als ein Gericht insbesondere bei einer letztinstanzlichen Entscheidung nicht gehalten ist, jedes Vorbringen in einer Entscheidung aufzugreifen.⁵³ Ob Vorbringen so zentral war, dass ein Schweigen der Entscheidung einen Gehörsverstoß indiziert, ist eine häufig nicht eindeutig zu be-

antwortende Bewertungsfrage. Insofern ist die Beurteilungssituation für die Partei misslicher als bei anderen Rechtsbehelfen. Eine weitere Besonderheit der Anhörungsrüge ist ihre eingeschränkte Funktion: Anders als im Rahmen anderer Rechtsbehelfe (zum Beispiel im Rahmen eines Revisionszulassungsantrages) kann eine Partei ihre eigentlichen (verfassungs-)rechtlichen Bedenken gegen die angegriffene Entscheidung im Rahmen der Anhörungsrüge häufig gar nicht geltend machen, sondern allenfalls bei Fortführung des Verfahrens nach erfolgreicher Rüge.

Die Konsequenzen einer Fehleinschätzung durch den Beschwerdeführer sind gravierend: Hat er davon abgesehen, eine Anhörungsrüge zu erheben, wäre die Erhebung nach Auffassung des BVerfG allerdings unter Subsidiaritätsaspekten geboten gewesen, so führt dies – soweit die gerügten Grundrechtsverletzungen und die mögliche Gehörsverletzung denselben Streitgegenstand betreffen – zur Unzulässigkeit der gesamten Verfassungsbeschwerde.⁵⁴

aa) Anhörungsrügenspezifische Subsidiaritätsmaßstäbe der Senatsrechtsprechung

Die Senatsrechtsprechung des BVerfG hat das Subsidiaritätsproblem, das die Anhörungsrüge aufwirft, aufgegriffen und die geschilderten, grundsätzlich sehr strengen allgemeinen Subsidiaritätsmaßstäbe modifiziert: Eine Verfassungsbeschwerde, mit der Art. 103 Abs. 1 GG nicht gerügt wird, scheitert nur dann am Subsidiaritätsgrundsatz, wenn den Umständen nach ein Gehörsverstoß durch die Fachgerichte naheliegt und vernünftige Verfahrensbeteiligte mit Rücksicht auf die geltend gemachte Beschwerde bereits im fachgerichtlichen Verfahren einen entsprechenden Rechtsbehelf ergreifen würden.⁵⁵

39 BVerfGE 134, 106 (113); BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 25.4.2005 – 1 BvR 644/05 (Queen Mary II), juris, Rn. 7 ff.

40 BVerfGE 134, 106 (113).

41 BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 25.4.2005 – 1 BvR 644/05 (Queen Mary II), juris, Rn. 10.

42 BVerfGE 134, 106 (113); BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 15.3.2006 – 2 BvR 917/05 u.a., juris, Rn. 14.

43 Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 381, 449.

44 Zu Besetzung und Funktionsweise dieser Abteilung siehe Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 14 ff.

45 Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 389, 520.

46 BVerfGE 126, 1 (18); Lenz/Hansel, a. a. O., Rn. 385 ff.

47 Ob die Möglichkeit der Zurücknahme der Art.-103-Abs.-1-Rüge überhaupt eine nennenswerte Bedeutung hat, wird selbst in der Spezialliteratur unterschiedlich eingeschätzt; vgl. einerseits (bejahend) Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 385 ff.; andererseits (verneinend) von Häfner/Kessen, § 93 BVerfGG und Subsidiarität der Urteilsverfassungsbeschwerde, in: Becker/Lange (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 3, 2014, S. 93 (104).

48 BVerfGE 134, 106 (115); st. Rspr.

49 BVerfGE 107, 395 (416 f.); 122, 190 (202 ff.).

50 Vgl. etwa BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 20.5.2013 – 1 BvR 1024/12, juris, Rn. 7 ff. zu einem Antrag auf Urteilsergänzung (§ 321 ZPO) bei unterbliebener Entscheidung über Nebenansprüche; auch an Anträge auf Tatbestandsberichtigung (§ 320 ZPO) ist zu denken (vgl. BGH, Beschluss v. 15.4.2010 – IX ZB 175/09, juris, Rn. 7); vgl. ferner BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 17.4.2015 – 1 BvR 3276/08 (zur Beschwerde gegen sitzungspolizeiliche Anordnungen nach § 176 VG, dort unter dem Gesichtspunkt fehlender Rechtswegerschöpfung).

51 Vgl. speziell zur Anhörungsrüge BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 15.3.2006 – 2 BvR 917/05 u.a., juris, Rn. 14 und v. 7.10.2016 – 2 BvR 1313/16, juris, Rn. 8; allgemein BVerfGE 79, 1 (20).

52 BVerfGE 68, 376 (381); BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 20.5.2013 – 1 BvR 1024/12, juris, Rn. 7; Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 13.10.2015 – 2 BvR 2436/14, juris, Rn. 17; zu auch insoweit bestehenden Darlegungslasten nach §§ 23 Abs. 1, 92 BVerfGG vgl. Lenz/Hansel, a. a. O., § 92 Rn. 68; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 6.12.2008 – 2 BvR 1082/08, juris, Rn. 21; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 20.5.2010 – 2 BvR 1226/09, juris, Rn. 4.

53 Vgl. oben bei Fn. 8 ff.

54 BVerfGE 134, 106 (115 f.).

55 BVerfGE 134, 106 (115 f.); krit. Allgayer, NJW 2013, 3484 (3486).

Danach greift das Subsidiaritätsgebot insbesondere dann, wenn auf der Hand liegt, dass das Beschwerdevorbringen der Sache nach auf die Rüge von Art. 103 Abs. 1 GG zielt, aber ersichtlich mit Rücksicht auf ein versäumtes Anhörungsrügeverfahren ausschließlich andere Grundrechtsverletzungen beanstandet.⁵⁶ In der (beschwerdeführerfreundlichen) Subsumtion unter diese Maßstäbe hat der Erste Senat in seinem Beschluss vom 16. Juli 2013 betont, dass der Vortrag in der dortigen Verfassungsbeschwerde eindeutig und sinnvoll in die Rüge einer Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG eingebunden gewesen sei.⁵⁷

bb) (Übermäßig) strenge Kammerpraxis

Die Kammerpraxis wird meines Erachtens den dargestellten Maßstäben der Senatsrechtsprechung in vielen Fällen nicht gerecht. Zum Teil werden die entwickelten Maßstäbe bereits zu Ungunsten des Beschwerdeführers verkürzt beziehungsweise missverständlich wiedergegeben.⁵⁸ Häufiger noch sind Kammerentscheidungen, die rigide Anforderungen daran stellen, wie ein vernünftiger Verfahrensbeteiligter in der Situation des Beschwerdeführers gehandelt hätte. So erachtete das BVerfG in einem Fall einen Gehörsverstoß als naheliegend und eine Anhörungsrüge als geboten, in dem der Beschwerdeführer im fachgerichtlichen Verfahren „nur ergänzend“ auf eine EMRK-Entscheidung hingewiesen hatte, auf die das Fachgericht nicht eingegangen war.⁵⁹ In einem anderen Sachverhalt, der einer Kammerentscheidung zugrunde lag, hatte ein Landesarbeitsgericht das (zutreffend zur Kenntnis genommene) Verhalten eines Bevollmächtigten bei Versäumung der Berufungsfrist in überstrenger Weise als schuldhaft bewertet, den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen und die Berufung verworfen.⁶⁰ Diese Überspannung der Anforderungen hatte der Beschwerdeführer mit der Verfassungsbeschwerde (zutreffend) als Verstoß gegen den allgemeinen Justizgewährungsanspruch gerügt. Das BVerfG betonte nun allerdings die Funktion der Wiedereinsetzung, den Zugang zum rechtlichen Gehör erst zu ermöglichen,⁶¹ und erkannte in dem fachgerichtlichen Vorgehen zugleich eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG, die der Beschwerdeführer mittels Anhörungsrüge nach § 78 a ArbGG hätte rügen können – und müssen, um zu vermeiden, dass seine Verfassungsbeschwerde der Subsidiarität zum Opfer fällt.⁶²

Diese und ähnliche Entscheidungen erscheinen kritikwürdig: Die Anforderungen daran, was für eine vernünftige Partei (und auch ihre Bevollmächtigten) „naheliegt“, werden in den Entscheidungen überspannt. Zudem lassen sie eine Beschäftigung mit dem Senatsmaßstab vermissen, ob die Anhörungsrüge für den Beschwerdeführer „mit Rücksicht auf die geltend gemachte Beschwer“ nahelag.⁶³ Die zwischen Art. 103 Abs. 1 GG und anderen Grundrechten bestehenden Überschneidungsbereiche lassen sie zulasten des Beschwerdeführers wirken, anstatt – was meines Erachtens richtig wäre – umgekehrt zu fragen, ob ein Beschwerdeführer sein Monitum sachgerecht einem anderen Grundrecht als Art. 103 Abs. 1 GG zugeordnet hat. Das in der Senatsentscheidung erkennbar angestrebte Ziel, die Fälle der Subsidiarität mangels Anhörungsrüge zu begrenzen und auf deutliche Fallgestaltungen wie eine strategische Vermeidung der Art.-103-Abs.-1-Rüge zu konzentrieren, wird durch diese Kammerrechtsprechung offenbar nicht weiterverfolgt.

2. Verfassungsbeschwerden nach erhobenen Anhörungsrügen

Die bisherigen Ausführungen könnten den Schluss nahelegen, eine Prozesspartei sei „auf der sicheren Seite“, wenn sie nach einem letztinstanzlich beendeten fachgerichtlichen Verfahren vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde noch ein Anhörungsrügeverfahren durchführt. Allerdings ist auch dieser Weg mit Risiken behaftet. Dies gilt es im Folgenden darzustellen, wobei wiederum zwischen Verfassungsbeschwerden unter Einschluss einer Art.-103-Abs.-1-Rüge (unter a)) und solchen, die einen Gehörsverstoß nicht weiter rügen (unter b)), zu unterscheiden ist.

a) Verfassungsbeschwerden mit Art.-103-Abs.-1-Rüge

Hat die Partei nach der letztinstanzlichen Entscheidung noch eine ablehnende Entscheidung über die Anhörungsrüge erwirkt und will sie auch im Verfassungsbeschwerdeverfahren die Verletzung rechtlichen Gehörs rügen, so sollte auch die Entscheidung über die Anhörungsrüge als Beschwerdegegenstand angegriffen werden.⁶⁴ Insofern ist – innerhalb der einmonatigen Verfassungsbeschwerdefrist (§ 93 Abs. 1 BVerfGG) ab Bekanntgabe⁶⁵ der Entscheidung über die Anhörungsrüge – den verfassungsprozessualen Substantiierungslasten auch mit Blick auf diese Entscheidung zu genügen. Somit muss der Beschwerdeführer auch diese Entscheidung vorlegen und sich mit ihr auseinandersetzen. Im Folgenden gilt es auf zwei Risiken aufmerksam zu machen, die mit der Durchführung eines Anhörungsrügeverfahrens vor Verfassungsbeschwerdeerhebung verbunden sein können.

aa) Subsidiaritätsrisiko bei nicht umfassender Anhörungsrüge

Sind dem Fachgericht mehrere Gehörsverstöße unterlaufen, mit der Anhörungsrüge jedoch nicht alle geltend gemacht worden, so besteht ein Subsidiaritätsrisiko. Nach einigen Kammerentscheidungen ist die oben geschilderte⁶⁶ „Subsidiaritäts-Logik“ auch auf diese Fälle der „unvollständigen Anhörungsrüge“⁶⁷ zu erstrecken: Eine umfassende Anhörungsrüge hätte die Chance geboten, dass das Verfahren wieder in den Stand vor dem ersten durchgreifenden Gehörsverstoß zurückversetzt worden wäre, und so die Möglichkeit eröffnet, sämtli-

⁵⁶ BVerfGE 134, 106 (116).

⁵⁷ BVerfGE 134, 106 (117).

⁵⁸ Vgl. BVerfG, Beschlüsse der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 25.8.2015 – 2 BvR 1554/15, juris, Rn. 2 und v. 14.4.2016 – 2 BvR 695/16, juris, Rn. 2; Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 4.5.2017 – 1 BvR 2584/16, juris, Rn. 8a.E.

⁵⁹ BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 4.5.2015 – 2 BvR 2169/13 u.a., juris, Rn. 4f.

⁶⁰ Die Rechtsbeschwerde (Revisionsbeschwerde) nach § 77 Satz 1 ArbGG war vom LAG nicht zugelassen worden, die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde war in dieser Situation seinerzeit noch nicht eröffnet (BAGE 150, 246; anders nunmehr § 77 Satz 2 ArbGG in der seit dem 17.11.2016 gültigen Fassung).

⁶¹ Vgl. dazu bereits oben bei Fn. 20.

⁶² BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 25.8.2015 – 1 BvR 1528/14, juris, Rn. 7ff.

⁶³ Vgl. auch Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 387.

⁶⁴ Vgl. die Ausführungen bei Gertler, Neuere Rechtsprechung (Fn. 35), S. 53 (65f.); die neueste Kammerrechtsprechung ist jedenfalls nicht durchgängig so streng, vgl. etwa Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats v. 9.3.2015 – 1 BvR 2819/14, juris, Tenor und juris Rn. 10. – Kommt das BVerfG zu dem Schluss, dass allein die Anhörungsrügenrechtscheidung rechtliches Gehör verletzt hat (insbesondere durch unrichtige Verwerfung der Rüge als unzulässig), so kann die Verfassungsbeschwerde keinen Erfolg haben, siehe BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats v. 22.5.2015 – 1 BvR 2291/13, juris.

⁶⁵ Bekanntgabe sei hier als Oberbegriff für die fristauslösenden Tatbestände des § 93 Abs. 1 Sätze 2 und 3 BVerfGG zu verstehen; siehe dazu im Einzelnen Lenz/Hansel, a. a. O., § 93 Rn. 30ff.

⁶⁶ Siehe dazu oben bei Fn. 41.

⁶⁷ Begriff bei Gertler, Neuere Rechtsprechung (Fn. 35), S. 53 (62).

che Gehörs- und sonstigen Grundrechtsverstöße zu korrigieren. Aufgrund dieses Gedankens ist in einigen Kammerentscheidungen die gesamte Verfassungsbeschwerde als unzulässig beurteilt worden.⁶⁸ Demgegenüber haben andere Kammerentscheidungen nur die nicht im Anhörungsrügeverfahren vorgebrachten Gehörsverletzungen als „gesperrt“ angesehen, während die Verfassungsbeschwerde bezüglich des zuvor bereits gerügten Gehörsverstößes beziehungsweise der anderen Grundrechtsrügen zulässig blieb.⁶⁹ Eine abschließende Klärung steht hier noch aus.

Für den Rechtsanwalt folgt daraus ein Grund mehr, bereits die Anhörungsrüge sorgfältig zu begründen und umfassend auf mögliche Gehörsverstöße einzugehen.

bb) Risiken bei fachgerichtlicher Verwerfung der Anhörungsrüge als unzulässig

In Fällen, in denen das Fachgericht die Anhörungsrüge als unzulässig verworfen hat, kann sich aus zwei Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde ein Unzulässigkeitsrisiko ergeben.

(1) Verfassungsbeschwerdefrist (§ 93 Abs. 1 BVerfGG)

Die erste Voraussetzung ist die Verfassungsbeschwerdefrist, die nach § 93 Abs. 1 BVerfGG einen Monat ab Bekanntgabe⁷⁰ der letztinstanzlichen Entscheidung beträgt. Wird nach einer letztinstanzlichen Entscheidung noch eine offensichtlich unzulässige (beziehungsweise nach zuweilen anzutreffender Diktion: „offensichtlich aussichtslose“⁷¹) Anhörungsrüge angebracht, so betrachtet das BVerfG den Rechtsweg als gleichsam „übererschöpft“ – so etwa dann, wenn „im Gewand der Anhörungsrüge tatsächlich nur die Richtigkeit der Ausführungen“ angegriffen wird.⁷² Die Verfassungsbeschwerdefrist wird dann nicht ab der Entscheidung über die Anhörungsrüge, sondern ab der Sachentscheidung berechnet – und ist dann im Zeitpunkt der Verfassungsbeschwerdeerhebung regelmäßig bereits verstrichen.

Ob eine Anhörungsrüge „offensichtlich unzulässig“ ist, kann in vielen Fällen zweifelhaft sein. Zwar wird sich eine Unzulässigkeit wegen Verfristung (das heißt mangels Wahrung der regelmäßig zu beachtenden Zwei-Wochen-Frist ab Kenntnis) häufig noch rechtssicher beurteilen lassen.⁷³ Ebenso ist die fehlende Statthaftigkeit der „sekundären Anhörungsrüge“⁷⁴ sowie der Anhörungsrüge gegen Anhörungsrügeentscheidungen („zweite Anhörungsrüge“)⁷⁵ geklärt. Größere Unwägbarkeiten kann die Statthaftigkeit der Anhörungsrüge aber in anderen Situationen aufwerfen, weil die Erkennbarkeit eines Gehörsverstößes (namentlich bei Nichteingehen auf Parteivortrag) Schwierigkeiten bereitet.⁷⁶

(2) Gebot ordnungsgemäßer Rechtswegerschöpfung

Noch problematischere Folgen kann die für Verfassungsbeschwerden bestehende Zulässigkeitsvoraussetzung einer *ordnungsgemäßen* Rechtswegerschöpfung⁷⁷ zeitigen. Regelmäßig geht das BVerfG in Fällen, in denen ein fachgerichtlicher Rechtsbehelf als unzulässig beurteilt wird, davon aus, dass der Rechtsweg nicht ordnungsgemäß erschöpft worden sei.⁷⁸ Dies ist bei Entscheidungen über Anhörungsrügen besonders misslich, weil hier in der gerichtlichen Praxis erhebliche Schwankungen in der Frage bestehen, ob eine Anhörungsrüge als unbegründet zurückgewiesen wird (weil ein Gehörsverstoß nach Ansicht des erkennenden Gerichts nicht vorliegt) oder ob schon eine Verwerfung als unzulässig erfolgt

(da ein Gehörsverstoß nach Ansicht des Gerichts nicht dargelegt ist).⁷⁹

Die Annahme einer nicht ordnungsgemäßen Rechtswegerschöpfung, wenn ein Rechtsbehelf als unzulässig beurteilt worden ist, gilt freilich nicht ausnahmslos: Hat das Fachgericht die Zulässigkeitsanforderungen in verfassungswidriger Weise überspannt, so scheitert die Verfassungsbeschwerde nicht am Erfordernis ordnungsgemäßer Rechtswegerschöpfung.⁸⁰ Ebenso ist eine unzulässige Anhörungsrüge dann verfassungsprozessual unschädlich, wenn das Fachgericht trotzdem (zumindest hilfsweise) auf die Begründetheit der Anhörungsrüge eingeht, schließlich sind die Zwecke des Subsidiaritätsprinzips dann erfüllt (nämlich die Aufbereitung der Sach- und Rechtslage für das BVerfG und die Möglichkeit der Selbstkorrektur für die Fachgerichte).⁸¹

Dieser Ansatz ist zu begrüßen, aber noch nicht ausreichend, um das Dilemma einer Prozesspartei zu lösen: Unter dem Blickwinkel des Subsidiaritätsgrundsatzes ist eine Partei schließlich gehalten, auch Rechtsbehelfe zu ergreifen, deren Zulässigkeit zweifelhaft sein kann (ohne dass die Partei diese Risiken ausschließen könnte).⁸² Macht sie von einem „wackeligen“ Rechtsbehelf Gebrauch und wird dieser sodann vom angegangenen Gericht in vertretbarer Weise als unzulässig beurteilt, darf der Partei ihr (verfassungsprozessual *sub specie* Subsidiarität gebotenes) Verhalten nicht verfassungsprozessual zum Nachteil gereichen. Daher ist es zutreffend, wenn das BVerfG in einer Senatsentscheidung vom 7. Dezember 2010 aus dem hier referierten Gedanken schlussfolgert, dass nur bei einem *offensichtlich* unzulässigen oder nicht ordnungsgemäß genutzten Rechtsbehelf der Rechtsweg nicht ordnungsgemäß erschöpft ist.⁸³

(3) Folgerungen und Abgrenzung gegenüber der Subsidiaritätssituation

Der die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde hindernde Vorwurf, ein zuvor eingelegter Rechtsbehelf sei „offensichtlich unzulässig“ gewesen und der Rechtsweg folglich nicht

68 BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 27.6.2007 – 1 BvR 1470/07, juris, Rn. 12 ff.; Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 22.5.2017 – 2 BvR 1107/16, juris, Rn. 13 ff.

69 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats v. 18.12.2008 – 1 BvR 2604/06, juris, Rn. 15 ff.; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 25.11.2010 – 2 BvR 2111/09, juris, Rn. 5.

70 Siehe oben Fn. 65.

71 Zur Uneinheitlichkeit vgl. Gertler, Neuere Rechtsprechung (Fn. 35), S. 53 (64 f.).

72 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 11.9.2015 – 2 BvR 1586/15, juris, Rn. 4.

73 Ein Spezialproblem stellt sich bei der (nicht fristgebundenen) Anhörungsrüge nach § 33 a StPO: Hier wird z. T. vertreten, dass § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG eine „Vorwirkung“ insofern entfalte, als die Anhörungsrüge nach § 33 a StPO binnen Monatsfrist zu erheben sei, wenn sie die Frist für eine spätere Verfassungsbeschwerde offenhalten solle; näher Lenz/Hansel, a. a. O., § 93 Rn. 20; von Häfen/Kessen, § 93 BVerfGG (Fn. 47), S. 93 (107 f.).

74 BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats v. 21.4.2013 – 1 BvR 423/11, juris, Rn. 10; zum Begriff der sekundären Anhörungsrüge s. o. bei Fn. 34.

75 BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats v. 26.4.2011 – 2 BvR 597/11, juris, Rn. 3 ff.; zum Begriff der zweiten Anhörungsrüge vgl. bereits oben bei Fn. 30.

76 Mit Recht krit. gegenüber der Rspr. daher Jost, Verfassungsprozessuale Probleme der Anhörungsrüge, in: Rensen/Brink (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 1, 2009, S. 59 (65 f.).

77 Vgl. Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 420 ff.

78 Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 434.

79 Vgl. Höger, jurisPR-BGHZivilR 19/2017 Anm. 3 unter Gliederungspunkt B.

80 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 20.4.2017 – 2 BvR 1754/14, juris, Rn. 40.

81 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 20.4.2017 – 2 BvR 1754/14, juris, Rn. 40; Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats v. 29.8.2017 – 2 BvR 863/17, juris, Rn. 13.

82 Siehe oben bei Fn. 48 ff.

83 BVerfGE 128, 90 (99 f.).

ordnungsgemäß erschöpft worden, sollte meines Erachtens sehr zurückhaltend eingesetzt werden. Auch sollte jedem nicht offensichtlich unzulässigen (und nicht nur jedem nicht offensichtlich aussichtslosen) Rechtsbehelf die Wirkung zuerkannt werden, die Verfassungsbeschwerdefrist nach § 93 Abs. 1 BVerfGG offenzuhalten.

Anders liegt es jedoch, wenn ein Rechtsbehelf nicht erhoben wurde und sich nun im Rahmen einer möglichen Ausnahme vom Subsidiaritätsgrundsatz fragt, ob der vom BVerfG erwogene vorrangige Rechtsbehelf „offensichtlich unzulässig“ war.⁸⁴ Da „offensichtlich unzulässig“ in der letztgenannten Fallgestaltung eine die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde eröffnende Funktion hat, kann das Kriterium dort weiter gehandhabt werden. Darüber hinaus sollte dem Beschwerdeführer bereits allgemein ebenso zugebilligt werden, von solchen Rechtsbehelfen abzusehen, die in der Sache offensichtlich aussichtslos sind (auch wenn sie zulässig sind oder ihre Zulässigkeit zumindest nicht offensichtlich fehlt).⁸⁵ Denn es wäre bloße Förmerei, auf ihrer Erhebung zu bestehen. Speziell bei nicht erhobener Anhörungsrüge greift schließlich der oben⁸⁶ geschilderte besondere Subsidiaritätsmaßstab aus BVerfGE 134, 106. So lässt sich zwischen dem Vorwurf nicht ordnungsgemäßer Rechtswegerschöpfung und den Subsidiaritätsfällen ein Korridor zugunsten des Beschwerdeführers herstellen, der rechtssicher gangbar sein dürfte.⁸⁷

b) Verfassungsbeschwerden ohne Art.-103-Abs.-1-Rüge

Hat der Verfassungsbeschwerdeführer ein Anhörungsrügeverfahren durchlaufen, so mag es sein, dass er die Rüge einer Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG nicht in die Verfassungsbeschwerde aufnehmen will – etwa weil ihn die Gründe des Beschlusses zur Anhörungsrüge vom Nichtvorliegen eines Gehörsverstößes überzeugt haben oder er einen Verstoß mittlerweile für geheilt hält.⁸⁸ In diesen Fällen ist es schlüssig, die Entscheidung über die Anhörungsrüge nicht zum Gegenstand der Verfassungsbeschwerde zu erheben. Gleichwohl hält die Anhörungsrüge (sofern nicht offensichtlich aussichtslos⁸⁹) die Frist für die Verfassungsbeschwerde offen, so dass die Frist ab Bekanntgabe der zurückweisenden Entscheidung über die Anhörungsrüge berechnet wird.⁹⁰ Im Rahmen der Verfassungsbeschwerdeerhebung muss auch die Entscheidung über die Anhörungsrüge – wiewohl nicht angegriffen – binnen der Monatsfrist vorgelegt werden. Nur so kann das BVerfG beurteilen, ob ein Beschwerdeführer seinen prozessualen Obliegenheiten aus den Gesichtspunkten der Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität genügt⁹¹ und die ab Bekanntgabe des Beschlusses zur Anhörungsrüge laufende Monatsfrist nach § 93 Abs. 1 BVerfGG gewahrt hat.

Im Übrigen können sich auch in dieser Situation die soeben (unter 2. a)) geschilderten Zulässigkeitsprobleme stellen, so dass auf die obigen Darlegungen verwiesen werden kann.

IV. Rechtssichere Handlungsmöglichkeit: „Parken im Allgemeinen Register“

Es dürfte deutlich geworden sein, dass erhebliche Unsicherheiten für eine Partei bestehen können, wenn diese nach einer ihr ungünstigen letztinstanzlichen Sachentscheidung den „Gang nach Karlsruhe“ erwägt: Will sie lediglich andere Grundrechte als Art. 103 Abs. 1 GG als verletzt rügen, muss sie gegebenenfalls befürchten, dass das BVerfG eine Anhö-

rungsrüge doch als Mittel beurteilt, welches eine vernünftige Prozesspartei erhoben hätte. Gleichzeitig muss sie unter Umständen besorgt sein, dass ihr gerade die vorherige Erhebung einer solchen Rüge „zum Verhängnis“ werden könnte. – Sieht die Partei demgegenüber einen Gehörsverstoß als gegeben an, liegt die vorherige Anhörungsrüge auf der Hand – allerdings droht auch insofern eine nachteilige Beurteilung durch Fachgericht und BVerfG dahingehend, dass die fachgerichtliche Anhörungsrüge und in der Folge auch die Verfassungsbeschwerde unzulässig seien.

Eine Lösung für dieses Dilemma bietet das sog. „Parken im Allgemeinen Register“. Darunter ist das folgende zweispurige Vorgehen zu verstehen: Die Anhörungsrüge wird fristgerecht erhoben. Zugleich wird (binnen Monatsfrist ab der Sachentscheidung) eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, wobei das BVerfG auf das laufende Anhörungsrügeverfahren hingewiesen und gebeten wird, die Verfassungsbeschwerde einstweilen nur in das Allgemeine Register aufzunehmen. Ergeht dann eine nicht stattgebende Entscheidung über die Anhörungsrüge, ist diese binnen Monatsfrist (§ 93 Abs. 1 BVerfGG) dem BVerfG vorzulegen, wobei zugleich die unter Substantiierungsgesichtspunkten notwendige Auseinandersetzung mit der Entscheidung über die Anhörungsrüge erfolgen muss. Zugleich ist die Übertragung der bis dahin „geparkten“ Verfassungsbeschwerde in das Verfahrensregister zu beantragen, womit die Beschwerde dann in ein richterliches Dezernat zur Bearbeitung und Entscheidung gelangt.⁹²

Ein solches Vorgehen wird vom BVerfG akzeptiert und ist in der Praxis üblich.⁹³ Der Vorteil liegt auf der Hand: Das oben geschilderte Dilemma, die sog. „Neunzigzwei-Dreiundneunzig-Fälle“⁹⁴, wird umschifft. Der Nachteil liegt darin, dass mit der praktisch gleichzeitigen Erhebung von Anhörungsrüge und Verfassungsbeschwerde ein hoher (Kosten-) Aufwand entsteht.⁹⁵ Hat die Anhörungsrüge Erfolg, so erledigt sich die Verfassungsbeschwerde, so dass die für den Erfolgsfall vorgesehene Kostenerstattung nach § 34 a Abs. 2 BVerfGG nicht eingreift. Das BVerfG verneint überdies eine Kostenerstattung aus Billigkeitsgründen gemäß § 34 a Abs. 3 BVerfGG.⁹⁶ Letztere Rechtsprechung erscheint änderungswürdig, schließlich wird ein zweispuriges Vorgehen durch die Rechtsprechung des BVerfG gerade herausgefordert.

⁸⁴ Vgl. dazu bereits oben bei Fn. 52.

⁸⁵ Fehlt etwa absehbarerweise der Beruhenszusammenhang und damit jede Erfolgchance der Anhörungsrüge, ist die Anhörungsrüge prozessual sinnlos (anders wohl BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 14.4.2016 – 2 BvR 695/16, juris, Rn. 3). In einem solchen Fall kann die Art.-103-Abs.-1-Rüge, bei der das BVerfG ebenfalls einen Beruhenszusammenhang i. S. e. potentiellen Kausalität prüft (vgl. Lenz/Hansel, a. a. O., § 92 Rn. 64), keinen Erfolg haben – wohl aber weitere Grundrechtsrügen. Diese Chance wird beschnitten, wenn man die Verfassungsbeschwerde bereits als unzulässig betrachtet (so der soeben zitierte Beschluss v. 14.4.2016).

⁸⁶ S. o. im Text bei Fn. 55 ff.

⁸⁷ Vgl. bereits Jost, Verfassungsprozessuale Probleme (Fn. 76), S. 59 (69).

⁸⁸ Vgl. BVerfGE 134, 106 (114); zur Möglichkeit der Heilung von Gehörsverstößen durch die Entscheidung über die Anhörungsrüge vgl. bereits oben bei Fn. 35.

⁸⁹ So BVerfGE 134, 106 (114); vgl. dazu bereits oben im Text bei Fn. 71 und unten unter Gliederungspunkt III.2.a)bb)(3).

⁹⁰ BVerfGE 134, 106 (114).

⁹¹ BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats v. 4.5.2017 – 1 BvR 2584/16, juris, Rn. 10.

⁹² Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 418 f.

⁹³ Siehe die entsprechenden Hinweise bei Lenz/Hansel, a. a. O., § 90 Rn. 405 f., 416 ff.

⁹⁴ Begriff von Lübbe-Wolff, AnwBl. 2005, 509 (513).

⁹⁵ Kritisch daher Rieble/Vielmeier, JZ 2011, 923.

⁹⁶ BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats v. 25.4.2015 – 1 BvR 689/15, juris, Rn. 3; Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats v. 2.5.2017 – 2 BvR 572/17, juris, Rn. 3.

V. Fazit

Als Fazit der hiesigen Überlegungen ergeben sich einerseits drei Hinweise für den Rechtsanwalt und andererseits drei Anregungen an das BVerfG.

1. Hinweise für den Rechtsanwalt

Für den Rechtsanwalt ergeben sich aus den obigen Darlegungen drei wesentliche Empfehlungen: Erstens ist von Verfassungsbeschwerden, die mit Art.-103-Abs.-1-Rügen „angedickt“ werden, ohne dass zuvor ein Anhörungsrügeverfahren stattgefunden hätte, in aller Regel nachdrücklich abzuraten. Zweitens sollte eine Anhörungsrüge sorgfältig begründet werden und auf sämtliche in Betracht kommenden Gehörsverstöße eingehen. Drittens schließlich ist in den (häufigen) Zweifelsfällen das „Parken im Allgemeinen Register“ als rechtssicherer, wenn auch aufwändiger Weg zu empfehlen.

2. Anregungen an das BVerfG

Das BVerfG sollte meines Erachtens in drei Punkten seine (Kammer-)Rechtsprechung zur Zulässigkeit modifizieren: Erstens sollte es den Unwägbarkeiten, die die Beurteilung eines Gehörsverstosses für die Verfahrensbeteiligten mit sich bringt, stärker Rechnung tragen und in den Kammerentscheidungen keine strengere Subsidiaritätsrechtsprechung praktizieren, als es den Maßstäben aus der Senatsentscheidung vom 16. Juli 2013 (BVerfGE 134, 106) entspricht. Bei Verfassungsbeschwerden, die nicht auf eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG gestützt sind, sollte die Prüffrage lauten, ob der Beschwerdeführer sein Monitum sachgerecht einem anderen Grundrecht als Art. 103 Abs. 1 GG zugeordnet hat. Der Prüfmaßstab sollte hingegen nicht lauten, ob auch eine Anhörungsrüge möglich (im Sinne von nicht aussichtslos oder sogar bloß nicht offensichtlich unzulässig) gewesen wäre.

Zweitens sollte das BVerfG in Fällen, in denen der Beschwerdeführer vor der Verfassungsbeschwerde eine als unzulässig beurteilte Anhörungsrüge erhoben hat, Folgendes zugrunde legen: Immer dann, wenn eine Partei den erhobenen Rechtsbehelf als nur möglicherweise zulässig beurteilen durfte, ist von einer ordnungsgemäßen Rechtswegerschöpfung auszugehen.

Drittens schließlich scheint die Rechtsprechung zur Auslagenerstattung nach § 34 a Abs. 3 BVerfGG korrekturwürdig: Wenn sich wegen einer erfolgreichen Anhörungsrüge eine parallel erhobene Verfassungsbeschwerde erledigt, sollte eine Kostenerstattung für das Verfassungsbeschwerdeverfahren aus Billigkeitsgründen nicht stets abgelehnt werden, sondern sogar umgekehrt regelmäßig erfolgen.



Rechtsanwalt Dr. Jan Felix Sturm, Hamburg

Der Autor ist Rechtsanwalt bei GvW Graf von Westphalen in Hamburg.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.